타당하다고 한 것으로 東京地決 平成12(2000). 1. 27. 金判 1120호 58면 ①(百選22) 참조]. 이 점은 '본래형'(民 제423조)에서는 당연하지만, 소위 '전용형'{轉用型}이더라도 피담보권리가 파산채권 또는 재단채권인 경우[등기청구권 보전을 위한 등기청구권의 대위행사(民 제423조의7)나 임차권 보전을 위한 방해배제청구권의 대위행사 등]에는 똑같이 타당하다고 해석된다. 이에 비해 피보전권리가 환취권이나 별제권인 경우(저당권 보전을 위한 방해배제청구권의 대위행사 등)에는 파산절차개시 후에도 중단되지 않고 소송절차는 그대로 속행된다고 해석해야 할 것이다. 후자의 사해행위취소권은 파산절차개시 후에는 동일한 목적을 가지는 부인권으로 일원화되기 때문에(파산절차개시 후에는 채권자가 새롭게 사해행위취소소송을 제기하는 것은 허락되지 않는다), 파산관재인이 원고로서 소송절차를 수계하고(破 제45조 제2항), 부인소송으로 소를 변경하게 된다. 또한 이 소송들도 파산절차가 중도에 종료되거나 한 경우에는 다시금 소송절차가 중단되며, 원래의 채권자가 수계하게 된다(동조 제4항~제6항).

나아가 채무자에 대한 파산절차개시에 의하여 강제집행절차에 대해서도 금지 등이 이루어진다. 즉 파산절차의 개시에 의해 파산재단에 속하는 재산에 대한 강제집행이나 가압류·가처분 등의 실행이 금지되며(破 제42조 제1항), 이미 이루어져 있는 것은 실효된다(동조 제2항 본문). '포괄집행인 파산절차의 개시에 의해 개별집행은 불가능하게 된다'는 것으로, 도산절차의 근간에 위치하는 법적효과이다[다만 파산절차개시 시점에 이미 강제집행이 종료되어 있는 경우에는 당연히 그 효과는 소급적으로 상실되는 것이 아니다. 이러한 경우에 어느 시점에서 집행절차가 종료

되었는지가 중요한 문제가 되는데, 배당이의의 소가 제기되어 배당액이 공탁되어 있던 경우에 채무자에 대한 파산절차가 개시되면, 그 집행절차는 아직 종료되지 않았던 것이기 때문에 실효된다고 한 것으로 最決 平成30(2018). 4. 18. 民集 72권 2호 68면(百選83)]. 다만 파산관재인은 파산재단을 위해서 강제집행절차를 속행하여(破 제42조 제2항 단서) 배당을 수령하는 것이 가능하다. 파산관재인이 강제집행에 의한 환가 쪽이 시간적·금전적으로 유리하다고 판단하는 경우에는 그 절차를 유용하는 선택지도 인정한다는 취지이다.

이상에 더해서, 파산자가 법인인 경우에는 파산절차개시결정이 이루어지면 그 법인이 해산되는 효과가 발생한다(一般法人 제148조 제6호·제202조 제1항 제5호, 会社 제471조 제5호·제641조 제6호 등). 법인에 관해서는 파산절차의 개시는 문자 그대로 법인격을 앗아가는 「사형의 선고」가 되는 것이다. 또한 통상적으로는 해산 후에 청산절차가 진행되지만, 이 경우에는 파산관재인에 의한 청산이 이를 대신하게 된다(一般法人 제206조 제1호, 会社 제475조 제1호·제644조 제1호 등 참조). 다만 파산절차가 개시되어도 파산법인의 법인격은 파산절차에 의한 청산의 목적 범위 내에서 절차의 종료에 이르기까지 존속하는 것으로 간주되며(破 제35조), 파산재단에 속하는 재산의 귀속주체 역시 파산법인이라고 여겨진다[그 관리처분권만이 파산관재인에게 전속된다(破 제78조 제1항)]. 파산절차종결결정의 공고(破 제220조 제2항)나 파산폐지결정의 확정에 의해 파산법인의 법인격은 소멸되고, 그 등기가 이루어지는 것에 의해 법인등기기록은 폐쇄된다(商登規 제117조 제3항).

(4) 별제권

(a) 별제권 행사의 절차

파산절차에 있어서 개별재산에 대해서 담보권을 가지는 담보권자는 원칙적으로 자유롭게 그 권리를 행사할 수 있다(3. (2) (b) 참조). 이러한 담보권자의 권리를 '별제권'이라 부른다(破 제2조 제9항). 파산재단으로부터 별도의 것으로서 제외할 권리라는 의미이다. 파산절차에서는 채무자의 재산이 최종적으로는 모두 환가청산되어 그 대금을 실체법의 순위에 따라서 배당하기 때문에, 사업체를 유지해서 그 수익 등으로 채권자에 대해서 변제를 하는 재건형의 절차에서와는 달리, 담보권의 실행을 제한할 필요는 원칙적으로 없다. 그래서 별제권은 파산절차에 의하지 않고 자유롭게 행사할 수 있도록 규정되어 있다(破 제65조 제1항). 따라서 예컨대 저당권자는 채무자에 대한 파산절차 중에도 집행재판소에 저당권의 실행(압류)을 신청해서 그 매각대금에서 배당을 받을 수 있다. 다만 별제권자가 담보권실행의 절차를 스스로 밟지 않는 경우에는 파산관재인이 별제권자를 대신해서 민사집행법 등의 규정에 의해 목적재산의 환가절차를 신청할 수 있다(破 제184조 제2항).

또한 별제권자가 담보권의 실행에 의해 채권을 전액 회수할 수 있는 경우에는 그것으로 충분하지만, 실행 후에도 잔존하는 피담보채권이 있는 경우(담보가 이른바 '오버론'{over loan}의 상태인 경우)에는 그 잔액에 대해서 파산채권자로서 권리를 행사할 수 있다(破 제108조 제1항 본문. 이 점에 대해서는 3. (2) (b) 참조). 다만 부동산시장이 침체되어 있는 경우에는 저당권의 목적물건이 경매절차에서 좀처럼 매각되지 않고 그 결과 부족액

채권을 파산절차에서도 행사할 수 없다고 하는 문제가 발생한다. 왜냐하면 만일 파산절차 쪽이 집행절차보다도 먼저 종결되어 버리면, 별제권자는 최후배당에 이르기까지 '담보권실행에 의해 변제를 받을 수 없는 채권액'을 증명하는 것이 불가능한 결과, 파산배당에서 제척되어 버리기 때문이다(破 제198조 제3항. 이 점에 대해서는 6. (2) 참조). 이러한 귀결에는 문제가 있기 때문에, 현행 파산법은 담보권자가 파산관재인과의 합의로 피담보채권의 범위를 축소하는 방식 등으로, 피담보채권의 일부를 목적물건에 의하여 「파산절차개시 후에 담보되지 않게 된 것」으로 하여, 그 채권부분에 대해서 파산절차에 참가할 수 있는 것으로 하고(破 제108조 제1항 단서), 나아가 근저당권의 경우에 한도액을 넘는 부분의 금액은 집행매각 전이라도 파산절차에서 배당을 받을 수 있는 것으로 하였다(破 제196조 제3항·제198조 제4항).

(b) 담보권소멸절차

별제권자·관재인은 집행절차에 따라서 목적물의 환가를 할 권한을 가지고 있지만, 집행매각은 아무래도 염가가 되어 버리기 때문에 실제로는 파산관재인이 별제권자의 동의를 얻어서 담보권을 소멸시켜 담보목적물을 임의매각하는 방식의 운용이 일반적이다[담보권이 붙은 채로 임의매각하는 것도 가능하고, 이 경우에는 별제권은 잔존하게 되나(破 제65조 제2항), 실제로는 그러한 예는 드문 것으로 보인다]. 그리고 그러한 경우에는 역시 별제권자의 동의를 얻어서 매각대금액의 일부(5%라고도 하고 10%라고도 한다)를 파산재단에 편입시키고 잔액을 별제권자에게 변제하는

(c) 담보권실행 중지명령

중지명령·포괄금지명령은 일반채권자를 대상으로 하는 것이지만, 사업 등의 재생을 위해서는 담보권의 실행을 제한하는 것도 중요하다. 이에 민사재생법은 담보권자에 대해서도 '담보권실행절차 중지명령'을 발령할 수 있도록 허용하고 있다(民再 제31조). 다만 담보권자는 실체법상 우선권·환가권을 가지고 있고, 또한 채무자의 도산 시에 대비하여 그 권리를 설정한 특성상 특히 보호의 필요성이 큰 채권자이므로, 그 권리실행을 제약하기 위해서는 일반채권자의 경우보다 더 엄격한 요건을 갖출 필요가 있다. 그래서 법은 담보권실행 중지명령의 요건으로 ① 재생채권자 일반의 이익에 부합할 것, ② 경매신청인에게 부당한 손해를 끼칠 우려가 없을 것을 요구하고 있다(民再 제31조 제1항). ①은 '경매의 중지에 의해 일반채권자가 이익을 얻는 경우'라는 것으로, 경매를 중지하고 그 재산에 기초한 사업을 계속함으로써 수익이 발생하여 일반채권자에 대한 변제가 증가하는 경우가 전형적이다. 다만 그러한 경우에도 ②의 요건이 필요하므로, 담보권자가 부당한 손해를 입는 경우에는 중지가 인정되지 않는다. 그러나 주의할 점은 중지명령을 하지 못하게 되는 것은 어디까지나 손해가 「부당」하다고 인정되는 경우에 한정된다는 점이다. 담보권 실행이 중지되면 항상 어느 정도의 손해는 담보권자에게 발생하게 된다. 이것을 가지고 중지할 수 없다고 한다면 이 제도는 기능을 할 수 없기 때문에, 중지명령이 부정되는 것은 어디까지나 부당한 손해가 발생하는 경우, 예를 들어 실행중지로 인해 도리어 담보권자 측이 파산의 위기에 빠지는 경우나 담보목적물의 가액이 급속히 감가될 우려가 있는 경우 등에 한정된다

는 것이다. 또한 중지명령의 대상이 되는 것은 별제권에 상당하는 담보권(6.(4) 참조)이지만, 이른바 '비전형담보'(양도담보, 소유권유보, 리스 등)의 취급에 대해서는 논의가 있다(제4장 II. 4.(4) 참조). 재건형 절차에 있어서의 담보권 제약의 중요성을 감안하여 유추적용을 인정해야 할 것이다(이 점은 입법화가 논의되고 있으며, 중지명령에 더하여 금지명령이나 취소명령도 가능하게 하는 방향으로 논의되고 있다. 제4장 II. 4.(4)(c) 칼럼「동산·채권담보법제의 입법과 도산절차」참조).

이외에도 담보권실행 중지명령에 대해서는 절차적으로도 제한이 가해지고 있다. 첫째, 재판소는 중지명령을 발령함에 있어서 반드시 경매신청인의 의견을 들어야 한다(民再 제31조 제2항). 위에 서술한 것과 같은 실체적 요건의 충족 여부에 대해 담보권자의 의견을 확인하고, 공격방어의 기회를 부여하려는 취지이다. 둘째, 실행의 중지는「상당한 기간」에 한정된다(동조 제1항). 일시적으로 실행중지가 이루어졌다고 하더라도 재생절차는 갱생절차와 달리 담보권을 절차에 끌어들이는 것이 아니므로, 그 이후에 어떤 조치가 취해지지 않으면 근본적인 해결이 되지 않는다. 생각할 수 있는 조치로는 ① 담보권자와 협의하여 별제권협정을 체결하는 것, ② 담보권소멸청구로 담보권을 소멸시키는 것 등이 있는데(6.(4) 참조), 실행중지명령은 그러한 조치가 취해질 때까지의 이른바 '때우기'인 잠정적인 조치인 것이다. 따라서 재판소는 위와 같은 근본적인 조치가 실현될 때까지의 기간을 상정하여, 상당한 기간을 정하여 중지명령을 발령하게 되는 것이다(거꾸로 말하면, 위와 같은 조치가 실현될 가능성이 전혀 없다고 인정되는 경우에는 중지명령이 발령되지 않는다는 것이 된다).

정한 경우에는 재생계획만으로 행할 수 있으므로, 회사법상의 절차를 필요로 하지 않고 인가된 재생계획의 정함에 따라 당연히 자본감소나 모집주식의 발행 등의 조치가 취해진다(民再 제183조·제183조의2). 또한 재생절차의 개시에 의해 중지되었던 집행절차·파산절차 등은 재생계획인가결정의 확정으로 인하여 (속행되고 있는 것을 제외하고) 그 효력을 잃게 된다(民再 제184조).

8. 재생계획의 이행확보

처음 부분에서 살펴본 바와 같이(I. 참조), 종래 화의절차의 가장 큰 결함으로 '화의조건의 이행을 확보하는 수단이 충분하지 않다'는 점을 들 수 있었다(「화의법은 사기법」이라는 비판이 있었다[43]). 그래서 민사재생법의 입법과정에서는 '재생계획의 이행을 어떻게 확보할 것인가'가 가장 중요한 과제로 대두되었다. 민사재생법은 이행확보에 이바지하는 몇 가지 규정을 두고 있다.

(1) 계획기간 중의 강제집행

먼저, 재생채권자표에 집행력을 부여하여 계획기간 중에도 강제집행이 가능하도록 하였다. 이 점과 관련하여, 화의법에서는 채권의 실체적 확정이 이루어지지 않은 결과로서 채권자표에 집행력이 인정되지 않았

43) 일본어에서는 '화의(和議, わぎ)'와 '사기(詐欺, さぎ)'의 뒤쪽 음절의 발음이 'gi(ぎ)'로 동일하다는 것을 염두에 두면 이해하기 쉬운 부분이다.

(7) 중지명령

주택융자에 관한 특칙은 채무자의 주택유지를 목적으로 하는 것으로, 최종적으로 재생계획인가라는 형태로 절차가 성공하면 그 시점에서 변제기한의 유예 등의 효과가 발생하지만, 그 이전까지는 그러한 효과가 발생하지 않아 채무자는 채무불이행 상태에 놓여 있는 경우가 많을 것이다. 만약 채권자가 그러한 채무불이행에 기초하여 저당권을 실행해서 재생절차 중에 주택을 매각하게 되면, 그 시점에서 주택자금 특별조항을 정하는 것을 불가능하게 된다. 따라서 이러한 사태가 발생하지 않도록 재생절차 기간 중에 담보권실행으로 인해 주택이 매각되는 것을 방지할 필요가 있다. 그래서 이미 존재하는 담보권실행절차 중지명령 제도(民再 제31조)에 더하여, 주택융자채권에 관련된 저당권실행절차 중지명령 제도가 규정되었다(民再 제197조). 그 절차 등은 통상의 담보권실행 중지명령과 동일하지만(동조 제2항), 통상의 중지명령과 비교했을 때의 이 중지명령의 특징으로는 ① 이 특칙이 재생채무자의 주택유지를 그 제도의 취지로 하기 때문에 '재생채권자 일반의 이익에 부합해야 한다'는 요건은 필요하지 않은 것으로 되어 있는 점, ② 같은 이유로 신청권자는 이해관계인이 아닌 재생채무자만으로 되어 있는 점, ③ 주택자금 특별조항으로는 주택융자채권자는 채권 전액을 변제받을 수 있고 그 법적 지위에 해를 입을 우려는 기본적으로 없으므로 '경매신청인에게 부당한 손해를 끼칠 우려가 없을 것'이라는 요건은 필요하지 않은 것으로 되었고, 그 대신 「주택자금 특별조항을 정한 재생계획의 인가 가능성이 있을 것」이 요건으로 되어 있다는 점을 들 수 있다(동조 제1항). 중지명령의 대상이 되는 것은

주택에 설정되어 있는 저당권에 더하여「재생채무자가 보유하고 있는 주택의 부지에 설정되어 있는」저당권이다(동조 제1항). 부지가 경매로 넘어가면 채무자는 주거를 유지할 수 없게 되기 때문이다.

〈참고문헌〉

伊藤眞{이토 마코토}『破産法·民事再生法(第5版)』{파산법·민사재생법(제5판)}(有斐閣, 2022년)

山本和彦ほか{야마모토 카즈히코 외}『倒産法概説(第2版補訂版)』{도산법 개설(제2판 보정판)}(弘文堂, 2015년)

松下淳一{마츠시타 준이치}『民事再生法入門(第2版)』{민사재생법 입문(제2판)}(有斐閣, 2014년)

山本克己編著{야마모토 카츠미 편저}『破産法·民事再生法概論』{파산법·민사재생법 개설}(商事法務, 2012년)

深山卓也ほか{미야마 타쿠야 외}『一問一答民事再生法』{일문일답 민사재생법}(商事法務研究会, 2000년)

花村良一{하나무라 료이치}『民事再生法要説』{민사재생법 요설}(商事法務研究会, 2000년)

全国倒産処理弁護士ネットワーク編, 才口千晴=伊藤眞監修{전국 도산처리변호사 네트워크 편, 사이구치 치하루=이토 마코토 감수}『新注釈民事再生法(上)(下)(第2版)』{신 주석 민사재생법(상)(하)(제2판)}(金融財政事情研究会, 2010년)

園尾隆司=小林秀之編{소노오 타카시=코바야시 히데유키 편}『条解民

재생채권자 전체를 대표하여 재생채권자의 이익을 보호하기 위하여 부여된 권한으로 생각할 수 있다. 그렇다면 그에 상응하여 그 의무 측면에서도 재생채무자가 재생채권자 전체를 위하여 권리를 행사하고 절차를 추행{追行}해야 한다는 점을 분명히 해야 한다고 생각되어 이러한 규정이 마련된 것이다. 실체법상 제3자에 대한 보호가 인정되는 상황에서도, 재생채무자는 제3자가 된다고 해석된다[예컨대 大阪地判 平成20(2008). 10. 31. 判時 2039호 51면(百選19)은 민법 제177조와의 관계에서 재생채무자의 제3자성을 인정하고 있다]. 다만 재생채무자의 제3자성이 반드시 완전한 형태로 관철되는 것은 아니다(파산관재인의 제3자성에 대해서는 제4장 II. 2. (2) 참조). 예컨대 부인권의 행사와 같은 것은 본래 재생채무자 본인에게 인정해도 되는 것이지만(미국에서는 그렇게 하고 있다), 스스로 자신의 행위의 효력을 번복하는 것은 채권자 등이 납득하지 못하는 점 등 여러 사정을 고려하여 감독위원에게 중립적인 입장에서 행사하도록 하고 있다(6. (2) 참조). 그러한 의미에서 재생절차에서의 DIP성은 다소 어중간한 수준에 머물러 있다.

(3) 개시결정의 효력

재생절차개시결정에 의해 발생하는 효력은 파산절차개시결정의 효력(제4장 II. 4. (1) 참조)과 대체로 일치한다(이하에서는 복습의 취지도 겸하여 간단하게 해설함). 우선 재생채무자의 재산에 대한 강제집행, 가압류·가처분 집행, 파산, 특별청산 등의 절차는 금지되고, 이미 계속되어 있는 절차는 중지된다(民再 제39조. 특별청산절차는 실효된다). 또한 재생

채권에 관한 소송절차는 중단되며(民再 제40조), 재생채권자가 제기하고 있는 채권자대위소송(民 제423조·제423조의7)이나 사해행위취소소송(民 제424조)도 중단된다(民再 제40조의2). 그 외의 재산관계 소송(예컨대, 재생채무자에게 귀속되어야 할 재산의 인도소송 등)은 파산절차의 경우와 달리 개시결정에 의해 중단되지 않는다. 이는 재생절차가 DIP형 절차이기 때문에 개시결정에 의해 재산의 관리처분권(당사자적격)은 변동되지 않는다는 것에 기초한 것으로, 관리명령의 발령에 의하여 비로소 중단의 효력이 발생한다(民再 제67조).

한편 재생절차개시 후에도 파산절차와 달리 재생채무자가 재산의 관리처분권을 유지한다는 점을 반영하여, 절차개시 후의 재생채무자의 법률행위도 당연히 유효하며 그 효력은 재생채무자의 재산에 귀속된다. 또한 재생채무자에 대하여 채무를 부담하고 있는 자는 절차개시 이후에도 재생채무자에게 변제하면 유효한 변제로서 보호받게 된다. 다만, 절차개시에 의해 대항관계가 발생하는 것은 파산절차의 경우와 동일하다(앞서 언급한 바와 같이 민법 제177조와의 관계에서 재생채무자는 「제3자」가 되고, 미등기권리자는 자신의 권리를 재생절차에서 주장할 수 없다). 왜냐하면 절차개시 후에는 채권자의 개별적인 권리행사가 금지되고 채권자의 주도로 대항관계에 진입(압류 등을 하는 것)할 수 없게 되므로, 채권자 보호를 위해서는 절차개시에 대항관계 발생의 효과를 인정할 필요가 있기 때문이다. 따라서 파산절차와 마찬가지로 재생절차개시 전에 발생한 등기원인에 기초하여 절차개시 후에 이루어진 등기는 재생절차와의 관계에서 원칙적으로 그 효력을 주장할 수 없다(民再 제45조). 판례도 자

기하게 된다 한다). 여기서의 이의소송은 통상적인 소송절차로서 심리판결이 내려지지만, 복수의 이의가 있는 경우에는 변론이나 재판의 병합강제 등 이를 합일적으로 심판하기 위한 특칙이 마련되어 있다(民再 제146조). 사정신청은 시효의 완성유예·갱신의 효력을 가지며(民再 제143조 제5항), 사정재판에 이의소송이 제기되지 않은 경우에는 그 재판은 확정판결과 동일한 효력을 갖게 된다(民再 제147조).

(4) 별제권 및 담보권소멸

민사재생법의 큰 특징은 '담보권에 대한 처우'에 있다고 할 수 있다. 재생절차에서는 저당권·특별선취특권 등의 담보권은 별제권으로 취급된다는 점에서 파산절차와 동일하며(民再 제53조), 담보권을 절차에 편입시키는 갱생절차와는 다르다[별제권의 범위 등에 대해서는 제4장 II. 4.(4) 참조. 또한 재생절차에서는 상사유치권은 당연히 별제권으로 취급되는 반면, 민사유치권은 파산의 경우(破 제66조 제3항)와 달리 실효되지 않으나, 별제권으로 취급되지도 않는다). 중소기업을 위한 절차인 재생절차에서는 '담보목적물의 평가'나 '조별분류(組分け)에 기초한 결의' 등의 제도를 마련하게 되면 절차가 너무 무거워지기 때문에 이러한 취급을 하게 된 것이다.

● **칼럼: 어음상사유치권에 기초한 재생절차개시 후의 추심·충당**

금융기관이 거래처의 어음을 추심위임 등으로 보유하고 있는 동안 해당 거래처에 재생절차가 개시된 경우, 금융기관은 '소지하고 있는 어음을 추심하는 등의 방법으로 채무변제에 충당할 수 있다'는 취지의 '거래약정 조항'에